

1500254-64.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, apurou-se que os denunciados associaram-se com ânimo estável e permanente para o desenvolvimento do tráfico de drogas no município de Avanhandava. JOSEMAR já foi processado pela prática deste crime (fls. 114/116) e, para o comércio de entorpecente no local, ele providenciou o aluguel da casa (fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500254-64.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500254-64.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSEMAR GOMES BARBOSA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de NILTON CARLOS RIBEIRO, vulgo "Du", qualificado às fls. 19 e 73, e JOSEMAR GOMES BARBOSA, vulgo "Jô da veia", indiretamente qualificado à fl. 4, dando-os como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese:

i) no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 7h30, na residência situada na Rua Borba Gato, nº 506, Bairro Residencial Antonio Tercei, no município de Avanhandava-SP, nesta Comarca de Penápolis, NILTON CARLOS RIBEIRO e JOSEMAR GOMES BARBOSA previamente associados para a prática do tráfico de drogas, assim agindo em unidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito drogas para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 11 (onze) saquinhos com "cocaína" (pesando 11,03 gramas), 34 (trinta e quatro) porções de "crack" e 5 (cinco) saquinhos com

"cocaína" (pesando 8,42 gramas), envolvendo na prática do crime o adolescente Vitor Hugo Ribeiro Conceição;

ii) de data pretérita até o dia acima citado, de maneira permanente, nas mesmas condições de lugar acima citadas, NILTON CARLOS RIBEIRO e JOSEMAR GOMES BARBOSA associaram-se, de maneira estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, apurou-se que os denunciados associaram-se com ânimo estável e permanente para o desenvolvimento do tráfico de drogas no município de Avanhandava. JOSEMAR já foi processado pela prática deste crime (fls. 114/116) e, para o comércio de entorpecente no local, ele providenciou o aluguel da casa (fl. 19), bem como controlava o ponto de venda de drogas, gerindo quais de seus comandados - entre eles NILTON (o "Du") e o adolescente Vitor Hugo ("Tito") - ficariam responsáveis pelos dias e horários (turnos) por ficar na "biqueira", cuidar da venda da droga e fazer as anotações do comércio.

De acordo com o MP, a polícia civil recebeu notícia de que JOSEMAR estaria a traficar atualmente no local acima mencionado, tendo realizado "campana" no local e presenciado grande movimentação de pessoas no local, entrando e saindo em curto espaço de tempo, pegando algo de modo dissimulado. Além disso, receberam notícias anônimas ("denúncias via 190") apontando JOSEMAR como o traficante daquele local (fl. 02 do apenso da Busca Domiciliar), foi assim que a Polícia Civil conseguiu, em apuração preliminar, identificar JOSEMAR como sendo o morador do local (fl. 03 do apenso) (fls. 46/47).

Consta que, com tais elementos, foi requerido e expedido mandado de busca domiciliar e no dia 11 de fevereiro de 2022 foi dado cumprimento a ordem judicial. No local, foram encontrados por ocasião da busca domiciliar o denunciado NILTON (Du) e o menor Vitor Hugo (Tito) na sala do imóvel, JOSEMAR não estava na residência naquele momento.

De acordo com a acusação, em revista pessoal, no bolso de NILTON foi apreendida a quantia de R\$ 2.249,50 em notas variadas e moedas, sendo dinheiro produto da venda de drogas, além de apreendidos 11 (onze) saquinhos contendo "cocaína". No quarto dos fundos, policiais apreenderam uma bolsa tipo pochete contendo 34 (trinta e quatro) porções pequenas de cocaína em forma de "crack", petrificadas, embaladas em plástico azul de sacola, 5 (cinco) saquinhos com "cocaína" e outra quantia em dinheiro em espécie, que somou R\$ 613,00 em notas diversas (cf. boletim de ocorrência de fls. 03/07 e auto de exibição e apreensão de fls. 14/16).

Na residência foram encontrados papéis com anotações do comércio de drogas (com descrição "óleo", "chá", "pó de 50" e "de 20"), 4 (quatro) telefones celulares (um da marca Samsung de NILTON Galaxy A21S; outro Samsung Galaxy A01 com o menor Vitor), também foram apreendidos outros 02 (dois) celulares deixados no local por usuários de drogas que compraram entorpecente - "LG rosa e Motorola preto".

Narra a denúncia que NILTON confessou o tráfico de drogas, dizendo que as 11 (onze) porções de cocaína encontradas com ele é "o pó de 50", a que se referem as anotações da contabilidade do tráfico. De sua vez, o adolescente Vitor Hugo, sobrinho de NILTON, informalmente disse ser proprietário da pochete encontradas as 34 porções de crack e outras 05 de cocaína. Aos policiais, por ocasião das diligências, NILTON e Vitor disseram que o dono da "biqueira" é JOSEMAR e que ganhariam dele "uma diária de 100 reais" para venderem droga.

Na delegacia (fls. 17/18), o menor Vitor Hugo negou a propriedade da droga, dizendo que "na hora lá assumi por conta do apavoro", indagado se vendia drogas para JOSEMAR, disse em solo policial: "já vendi esses, mas hoje não mais". No interrogatório na Delegacia (fl. 19), NILTON disse que vendia drogas há cerca de 30

dias no local e que a casa estava alugada em nome de JOSEMAR, porém negou a participação deste, dizendo que "faz o corre separado" e que o "pó maior vende a 50 reais" e o "pó menor vende a 20 reais", explicando que o restante vende a 10 reais cada, auferindo cerca de "600 reais brutos por dia" na venda de drogas.

Por fim, consoante o MP, com a apreensão dos telefones celulares e a respectiva autorização judicial para acesso aos dados nestes aparelhos, foram submetidos à perícia, obtendo-se conversas entre NILTON e Vitor Hugo sobre o tráfico de drogas em questão, inclusive com solicitação do adolescente ("Tito") de que NILTON conversasse com JOSEMAR para que este decidisse se seria ele (o menor) o responsável por cuidar do ponto da venda de drogas num dia, perguntando "Cadê o jo pergunta para ele se é pra mim ficar lá agr de dia" (fl. 81, reproduzida no laudo, à fl. 172), seguida da informação de outra anotação da contabilidade do tráfico naquela noite (relatório de fls. 74/81). Os laudos periciais nos exames dos celulares evidenciam conversas sobre o tráfico de drogas (fls. 163/226), até mesmo envolvendo outras pessoas.

NILTON foi preso em flagrante delito, tendo sido convertida em prisão preventiva (fls. 1, 121/125 e 152/153). JOSEMAR teve sua prisão preventiva decretada, mas está foragido (fl. 257).

Notificado (fl. 324), o réu NILTON apresentou defesa preliminar (fls. 320/322).

Apesar de não citado/notificado, pois encontra-se foragido (fl. 257), o réu JOSEMAR apresentou defesa preliminar (fls. 325/328).

A denúncia foi recebida no dia 7.6.2022 (fls. 338/341).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 478/479), 1 (uma) testemunha de defesa (fl. 477), sendo os réus interrogados ao final (fls. 473/474 e 475/476).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 469/471).

A defesa do réu Josemar Gomes Barbosa, em suas alegações finais, requereu reconhecimento da nulidade da busca e apreensão domiciliar e, ainda, da quebra de sigilo de dados, vindicando a absolvição do acusado (fls. 480/484).

A defesa do réu Nilton Carlos Ribeiro, em suas alegações finais, requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea, com aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da LAD (fls. 485/487).

II - Da Fundamentação

De início, inexistiu nulidade na prisão em flagrante e/ou na busca e apreensão, porquanto não configurada invasão ilegal de domicílio pelos policiais.

Não se nega, aqui, a importância da inviolabilidade do domicílio, considerada garantia individual pelo artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, do seguinte teor: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

Nada obstante, ao mesmo tempo em que tutela a inviolabilidade do domicílio, a Constituição Federal prevê limitações à proteção desse direito.

Ensina o constitucionalista MARCELO NOVELINO¹ que "De acordo com o dispositivo constitucional em apreço, a entrada em uma casa, sem o consentimento do morador,

somente poderá ocorrer no caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, XI). Em virtude do caráter emergencial, nas três primeiras hipóteses (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), a casa poderá ser invadida a qualquer hora do dia ou da noite”.

Logo, ainda que de índole constitucional, a garantia em estudo não é absoluta, admitindo o seu sacrifício quando no interior da residência esteja ocorrendo a prática de crime.

Para que haja o ingresso regular e válido em domicílio alheio, necessária a demonstração de um contexto fático delituoso anterior à própria invasão, considerado como "justa causa" para a flexibilização da inviolabilidade do domicílio.

Não por outro motivo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus Coletivo nº 598051/SP, julgado em 02.03.2021, sob a Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, consignou que somente a existência de "fundada suspeita" aquela que permita concluir pela ocorrência de crime antes do ingresso de policiais na residência é que poderá justificar a mitigação do direito fundamental em questão. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (...) O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [] A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. [] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). [] (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) (ressalvo negritos e sublinhados)

Assim, uma vez que ocorreu flagrante dentro do imóvel, a estrita observância das exigências para cumprimento do mandado de busca domiciliar/apreensão (como acompanhamento pelo dono ou vizinho) fica prejudicada, sendo legitimada a conduta dos policiais.

No caso, mesmo que não notificado nenhum vizinho ou parente a acompanhar o cumprimento do mandado no imóvel, foi encontrado no local, de qualquer modo, o montante de 11 (onze) saquinhos com "cocaína" (pesando 11,03 gramas), 34 (trinta e quatro) porções de "crack" e outros 5 (cinco) saquinhos com "cocaína" (pesando 8,42 gramas), o que, portanto, legitimou o ingresso no imóvel sem as formalidades invocadas pela Defesa.

De qualquer modo, ainda que assim não fosse, a busca foi acompanhada pelo corréu Nilton, conforme seu depoimento na DP, o que também faz cair por terra a tese de inexistência de acompanhamento do ato por civil.

Também não vinga a insurgência quanto à quebra de sigilo de dados, impugnação que, aliás, causa estranheza, já que o réu nega relação com o celular periciado.

De qualquer modo, com a aludida apreensão de droga no imóvel, a referida quebra mostrou-se lógica e necessariamente complementar, tudo com fito de esclarecer o contexto fático de possível traficância com o qual se depararam os policiais por ocasião do cumprimento do mandado de busca, inclusive em relação ao réu Josemar, dada a notícia de seu envolvimento com o tráfico confirmada, segundo alegaram os policiais civis, pelo outro correu e o o adolescente presente na casa naquela ocasião do referido cumprimento.

Pois bem.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); ii) boletim de ocorrência (fls. 3/7); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 14/16); iv) laudos de constatação prévia (fls. 37/45); v) laudos periciais em telefones celulares (fls. 163/226); vi) laudo pericial definitivo para cocaína (fls. 239/241); vii) laudo pericial definitivo para cocaína (fls. 247/249); viii) auto de incineração da droga (fls. 253/256); ix) laudo pericial complementar em telefone celular (fls. 286/319); e x) laudo pericial de folha de papel (fls. 399/406).

Resta saber se a autoria delitiva foi comprovada pela prova oral.

A Testemunha/C PC LUCAS PONTES PESSOA disse que participou da investigação e recebiam constantes denúncias de que um rapaz moreno alto, vulgo “JÔ da Veia”, estaria comercializando drogas e, no tal endereço, constataram haver movimentação, pelo que conseguiram mandado de busca e entraram na casa, encontrando Nilton e o tal menor. O alvo, até então, era Josemar. Dentro da casa, os 2 estavam olhando pela janela. Com Nilton, encontraram mais de 2000 reais e mais 11 porções de cocaína. Com o menor nada encontraram. Num quarto do fundo encontraram mais 34 porções de crack e 5 de cocaína, tendo Victor assumido, mas depois retratou-se, tendo, por fim, Nilton falado que a pochete era dele. Ambos disseram que vendiam e que ganhavam 100 reais pela diária. Disseram que Josemar, casada com sobrinha do Nilton, e irmã do Victor Hugo, pagava a eles, já que estavam desempregados. Quanto à casa ser locada por Josemar, acha que sim, mas não tem certeza. Em campanhas, já viram Josemar, por várias vezes, nesse imóvel, inclusive a amásia Nayara, tanto que, no dia da busca, acharam que eles estariam lá, mas acabaram encontrando Nilton e Victor. Quando cumpriram o mandado de busca, não chamaram nenhum vizinho, pois, de qualquer modo, tinham 2 pessoas lá dentro. Fizeram apenas um relatório ao DP, porém várias campanhas. A informação que tinham é que o casal morava lá e tinha movimentação de gente, mas não conseguiam ver o que se entregava lá. A campanha durou por volta de 1 semana e o fluxo maior era de quinta para frente, pois, de semana, não havia muito movimento. Quanto aos compradores vistos durante a campanha, nenhum foi abordado, pois, se abordam, isso acaba “queimando” o veículo. Também não abordaram Josemar entrando e saindo da tal casa. Nilton não era conhecido dos meios policiais.

A Testemunha/C PC Fabio Pontim disse que participou da investigação. Houve denúncia anônima e fizeram campanha, vendo pessoas transitando em frente à casa, pelo que fizeram relatório e, em seguida, busca no imóvel, constatando a presença dessas drogas. Encontraram no imóvel o Du e o menor. Du a estava com drogas no bolso, tendo ele dito que era do Josemar e que estava vendendo, bem como apreendida uma quantia em dinheiro com ele, em seu bolso. Participou também das campanhas. Da busca

e apreensão participaram o depoente e o Lucas. Quando Duzinho confirmou que estava vendendo drogas para Josemar, o PC Lucas também estava dentro da casa e não lembra se ele chegou a ouvir essa confissão. Nesse entre e saiu de pessoas (campana), notou que havia um carro vermelho, um Peugeot, e ele ia lá também (viu). Não lembra por quanto tempo, mas foi em janeiro. Nilton não era conhecido dos meios policiais. Quanto à campana, não abordou ninguém das pessoas que entraram e saíram do imóvel. Quanto à presença do carro vermelho, não mencionou tal fato na DP porque ateve-se tão-somente à apreensão.

A Testemunha/D Jesias Cardosa disse que é proprietário do imóvel da ocorrência. Não conhece Josemar e alugou para o Duzinho, em agosto de 2021. Duzinho pagava R\$ 350,00 de aluguel. Perguntado sobre a informação dada por Nilton – casa era biqueira e alugada por Josemar – disse que não conhece Josemar e alugou o imóvel para Nilton. O depoente mora em Penápolis. Chegou a ir lá receber aluguel no local umas 2 ou 3 vezes e nunca viu Josemar lá até então. Tratou o aluguel diretamente com o Nilton, que o procurou. Alugou sem contrato escrito. Nilton prestava serviço para a Prefeitura. Sobre a campana feita pela polícia no imóvel, nada pode dizer pois estava em Penápolis e não ficou sabendo disso. Depois que a polícia encontrou droga lá, pegou a casa de volta e alugou para um pessoal que trabalha na lavoura.

Em seu interrogatório, NILTON CARLOS RIBEIRO disse que o policial Fábio faltou com a verdade, pois ele foi um dos que o abordou e que teria dito que a droga fosse do Josemar e não disse isso. Fábio chegou perguntando do Josemar e mandando-os entregarem-no, pois a pena seria menor, pois sabiam que a droga era do Josemar. Tinha uma droga no seu bolso realmente e, no apavoro, até esqueceu dessa droga no bolso. Então disse que não tinha mais droga. Então, abordaram o menor, que estava lá e só para mexer no wifi. Ele estava no banheiro. A droga encontrada era dele e realmente vendia a droga. O adolescente não participava da venda e só ia lá para mexer no wifi. Sobre o dinheiro, mais de R\$ 2.240,00, em notas de R\$ 50,00 e R\$ 200,00, eram seus e não eram fruto de droga, mas sim oriundos de sua conta bancária, que conseguiu trabalhando. Sacou esse dinheiro porque foi pagar um salgado no bar e tentou pagar com o cartão, ficando sabendo que estava bloqueado, pelo que foi ao banco tentar resolver e então zerou sua conta enquanto regularizava a conta (teve que levar comprovante de residência, etc.). Trabalhava na época na limpeza da cidade, em uma empresa terceirizada e ganhava por volta de R\$ 1.150,00 e ajudava só sua irmã. Sobrava dinheiro para fazer poupança. A droga que estava com ele começou a comercializar “fiado” e anotando. Não tinha ninguém por trás dessa situação. Vendia droga há 30/40 dias. Quanto a Josemar, é casado com sua sobrinha e, como ele bateu nela, foi cobrar dele e, por isso, acabaram se afastando nos últimos tempos. Sobre seu depoimento na DP – que a casa foi alugada pelo Josemar – disse que não se lembra de ter dito isso lá e, quanto a dizer que trabalhava para Josemar, também nega ter dito isso na DP ou que vendesse droga para ele. Conhece Josemar há bastante tempo e não sabe se ele é traficante, mas acha que ele já foi condenado por tráfico. Está arrependido do que fez e nunca teve envolvimento com a Justiça até então. Não leu seu depoimento na DP e não estava acompanhado de advogado.

Em seu interrogatório, JOSEMAR GOMES BARBOSA disse que está foragido e prefere não dizer seu endereço. Nega que tenha relação com essa casa, pois morava na Vila Industrial e, quanto às mensagens mencionando seu número, não tem relação com seu número, que é outro, com DDD14. Acha que os PMS inventaram isso pelos maus antecedentes e porque não gostam dele. Ele já apanhou do primeiro policial em outra abordagem. Já foi condenado por tráfico. Trabalha com lenha, assim como seu pai. Seu pai compra lenha e o depoente corta. Ele compra eucalipto, o depoente corta, pagam frete e levam para cerâmica. Na época, fazia isso e no dia estava fazendo esse tipo de trabalho. Ganhava por volta de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00 por mês. Não ia à tal casa. O tal Peugeot não é dele e usou esse carro, de seu colega, uma vez só para buscar serra. Está em outra cidade e está se virando da forma como pode, contando com ajuda de sua família. Nunca mais vendeu droga depois da condenação por

tráfico. Não chegou a conversar com Nilton depois dessa ocorrência. Quanto a Victor Hugo ter dito que já vendeu droga a mando do depoente, nega tal questão.

Pois bem.

O conjunto probatório é conclusivo, apto, pois, a embasar a condenação de ambos os réus, em relação a ambos os crimes (tráfico e respectiva associação).

Os milicianos ouvidos foram claros em seus depoimentos, tanto em fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a dinâmica em que se deu o cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive quanto à quantidade de droga apreendida e o numerário.

De fato, os policiais civis confirmaram, na DP e em juízo, que já havia denúncia da prática do tráfico de drogas pelo réu Josemar, vulgo "Jô da veia", o que corrobora com disposto no relatório de fls. 46/47.

Disseram que, no dia dos fatos, deram cumprimento ao mandato de busca e apreensão e localizaram o réu Nilton e seu sobrinho menor de idade no local. Lograram êxito ao encontrar no bolso do réu Nilton a quantia de R\$ 2.249,50 e 11 (onze) saquinhos de cocaína. Além disso, também foram apreendidos 34 (trinta e quatro) porções de crack, 05 (cinco) saquinhos de cocaína, mais R\$ 613,00, anotações relacionadas a venda de entorpecentes e quatro celulares.

Os policiais civis confirmaram também que, na ocasião, o réu Nilton e seu sobrinho confessaram informalmente que traficavam as drogas, que aquele local funcionava como "biqueira" e que ganhavam uma diária de R\$ 100,00 para traficar para o réu Josemar, vulgo "Jo da veia".

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente os acusados, imputando-lhes o delito de tráfico de drogas, não se mostrando que incriminariam aleatoriamente os réus sem qualquer motivo anterior que justificasse tamanha ilegalidade. São funcionários públicos no exercício de suas funções e depõem em Juízo sob o dever de dizer a verdade.

O réu Nilton, na DP (fl. 19), confessou a prática do delito de tráfico de drogas, confirmando que as drogas apreendidas, o dinheiro e as anotações encontradas eram suas. Apesar de negar que trabalhava para o réu Josemar, disse que a casa em que se deu a busca e apreensão estava alugada em nome de Josemar. Em Juízo, a versão foi diversa, embora tenha dito que a droga era sua, para a venda, afastou, por outro lado, qualquer envolvimento ou participação de JOSEMAR.

O réu Josemar, em Juízo, negou a traficância, bem como qualquer envolvimento com o réu Nilton ou com o imóvel mencionado na denúncia.

Ora, como visto, NILTON confessou a traficância, informando que a droga com ele encontrada é “o pó de cinquenta” constante na anotação. Vitor Hugo também disse que participa do tráfico e assumiu a propriedade da pochete, com drogas e dinheiro. Ambos confirmaram que o local funciona como “biqueira”, cujo “dono” é JOSEMAR, vulgo “Jô da Veia”. O adolescente, Vitor Hugo Ribeiro Conceição, alegou que já vendeu droga para o “Jo da Véia”, apelido de JOSEMAR, seu cunhado (fls. 17/18).

Ainda no tocante ao tráfico, bem como em relação à associação entre ambos para a prática criminosa, os diversos laudos periciais acostados aos autos demonstram que havia entre eles uma associação permanente e estável voltada ao tráfico de drogas, conforme se depreende das trocas de mensagens e áudios transcritos às fls. 163/226, 286/299 e 300/319, além de anotação de contabilidade do tráfico às fls. 399/406. A divisão de tarefas ficou bem caracterizada nas provas dos autos, inclusive com envolvimento de adolescente.

Analisando tais anotações, percebe-se que JOSEMAR providenciou o aluguel da casa (fls. 19) e controlava o ponto de venda de drogas, gerindo quais de seus comandados - entre eles NILTON (o “Du”) e o adolescente Vitor Hugo (“Tito”) - ficariam responsáveis pelos dias e horários (turnos) na “biqueira” (fls. 172/174), tudo a evidenciar a traficância bem como o vínculo de permanência entre ambos na prática criminosa.

A associação dos réus também fica clara pelo depoimento dos policiais que afirmam que o réu Nilton e o menor confessaram que trabalhavam para Josemar por uma diária de R\$ 100,00, pelo relatório que deu origem à busca e apreensão, na qual apontam Josemar como traficante do local (fl. 02 do apenso da Busca Domiciliar) e pelas conversas extraídas dos celulares apreendidos às fls. 163/197.

Embora o menor, sobrinho do réu Nilton, tenha falado na DP (fl. 17/18) que as drogas e o dinheiro apreendido na pochete não lhes pertenciam, afirmou que já vendeu drogas anteriormente para o réu Josemar. Além disso, na perícia realizada no celular do réu Nilton, na conversa com o menor às fls. 168/174, indica que ele ainda participava do tráfico de drogas com os réus.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, ficou cabalmente demonstrada que a quantidade de droga apreendida (11 porções de cocaína, 34 porções de crack, 5 porções de cocaína), a forma como estavam fracionadas/embaladas (divididas em vários saquinhos), a dinâmica da busca e apreensão e prisão, denotam que as substâncias apreendidas em poder dos denunciados se destinavam ao consumo de terceiros.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

II.a. Do réu Nilton Carlos Ribeiro

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, já que tem bons antecedentes (fls. 363/364), pelo que fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em:

* 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

Na segunda fase, sem agravantes. Incide, porém, a confissão espontânea como atenuante apenas quanto ao tráfico (ele não confessa a associação), o que, por outro lado, não tem o condão de diminuir a pena, já fixada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, há de incidir a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (aumento de 1/6), vez que foi provado o envolvimento do adolescente no delito, pelo que as penas passam a ser de:

* 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

De fato, a considerar os diálogos consignados nas mensagens de whatsapp do celular do acusado às fls. 172/197, percebe-se que o réu já vinha traficando há vários dias, o que denota, de sua parte, dedicação à atividade criminosa, o que, portanto, impede o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, as penas perfazem o montante de:

* 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006)

O regime a ser fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, o único compatível com a gravidade do crime cometido e, exatamente por isso, ser imposto legalmente (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois

o quantum da pena imposta impede tal substituição (art. 44, I, do CP).

II.b. Do réu Josemar Gomes Barbosa

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, pois conta com maus antecedentes (0011116-72.2008.8.26.0438 - fls. 367/368 e 0012324-91.2008.8.26.0438 - fls. 368/670 - condenações há mais de 5 anos), pelo que fixo a pena inicial acima do patamar mínimo (aumento de 1/6), a saber:

* 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, há de incidir a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (aumento de 1/6), vez que foi provado o envolvimento do adolescente no delito, pelo que as penas passam a ser de:

* 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

De fato, a considerar os maus antecedentes do acusado, principalmente por haver condenação pelos mesmos delitos do caso em análise (fls. 368/370), além do teor do relatório que deu origem à busca e apreensão à fl. 02 do apenso da Busca Domiciliar, percebe-se que o réu dedica-se à atividade criminosa, o que, portanto, impede o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, as penas perfazem o montante de:

* 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

O regime a ser fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, o único compatível com a gravidade do crime cometido e, exatamente por isso, ser imposto legalmente (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o quantum da pena imposta impede tal substituição (art. 44, I, do CP).

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a acusação penal para:

III.a. CONDENAR Nilton Carlos Ribeiro, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de:

* 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e

oitenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

O montante que resulta da soma de ambas penas é de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no menor valor.

III.b. CONDENAR Josemar Gomes Barbosa, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de:

* 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor para o crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e;

* 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no menor valor para o crime de associação (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

O montante que resulta da soma de ambas penas é de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 1.633 (um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois há envolvimento de adolescente em crime tão grave, além do quantum das penas impostas impedir tal substituição (art. 44, I, do CP).

Nego o direito aos réus de apelarem em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população. Além disso, trata-se de crime que movimenta toda uma estrutura criminosa (refiro-me à teia de pessoas formada pelo trabalho de vários infratores, porém sem a noção/ciência de que estão trabalhando em conjunto), o que só denota a necessidade de sua clausura, como forma de manutenção da ordem pública – trata-se de prisão cautelar e não decorrente unicamente da presente condenação. Recomendo o réu Niton na prisão em que se encontra recolhido. E quanto ao réu Josemar, mantenho a decisão de fls. 121/125.

Decreto o perdimento do numerário e dos celulares apreendidos nos autos, dada a comprovação de sua origem ilícita.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

Custas na Forma da lei.

P.I.C.

Penápolis, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA